

1500208-79.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º ("tráfico privilegiado") deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500208-79.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-79.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026278/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22708708 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 458/22/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2026278 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CICERO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

JOSÉ CÍCERO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333, caput, do Código Penal, em concurso material, porque no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 02h40min, na Estrada Alice Pereira de Souza, altura do nº 200, bairro Taquacetuba, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, trazia consigo, no interior de uma mochila, para fins de traficância, drogas consistentes em: a) 16,5g (massa líquida) de cocaína, fracionados em 28 invólucros plásticos; e b) 4,25g (massa líquida) de cocaína na forma de crack, acondicionados em 31 microtubos plásticos do tipo eppendorf, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 81,00 (oitenta e um reais) em espécie, produto da mercancia ilegal, consoante laudo de constatação provisória de págs.15/16, auto de exibição e apreensão de págs.18/19 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 91/93.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, JOSE CÍCERO DA SILVA, qualificado nos autos, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Alan dos Santos Canario e Victor Pimenta Mariano, para determiná-los a omitirem ato de ofício, qual seja, sua prisão em flagrante.

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais militares estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos, ocasião em que um transeunte apontou que nas imediações estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Os policiais, então, se dirigiram ao local indicado, momento em que avistaram o acusado com uma mochila vermelha nas costas, o qual começou a correr assim que avistou a viatura policial, tentando se evadir.

Imediatamente, os policiais o acompanharam e, sem perdê-lo de vista, presenciaram quando o acusado adentrou a um matagal e se abaixou, visando se esconder.

Ato seguinte, os policiais ingressaram no referido matagal e lograram êxito em abordar o acusado, ainda com a mochila vermelha nas costas.

No interior da mochila, foram encontradas 31 porções de crack e 28 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 81,00 (oitenta e um reais) em notas de pequeno valor.

Diante de tais fatos, os policiais militares informaram o acusado que o conduziram à Delegacia de Polícia, oportunidade em que ele lhes ofereceu dinheiro, tentando convencê-los a não efetuarem sua prisão. Após isso, o acusado foi algemado e levado à presença da Autoridade Policial.

Considerando a significativa quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento (em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros), assim como as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, que envolveu tentativa de fuga diante da presença dos policiais militares, não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial a págs. 05/71. Notificado (pág.120), o réu ofertou defesa preliminar (pág.124) Recebida a denúncia às págs. 125/136, o réu foi citado (pág.134). Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, a acusação pretende a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos

demonstra com clareza a confluência das elementares dos delitos de tráfico de substância entorpecente e corrupção ativa, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade do delito de tráfico vem demonstrada no auto de exibição e apreensão de págs. 18/19 (dinheiro, mochila e droga), nos laudos de constatação às págs.15/16 (repetido às págs.88/90), químico-toxicológico às págs.91/93 e pericial (mochila) às págs. 127/128, bem como no comprovante de depósito de pág.69.

Quanto à autoria, na fase policial o acusado ofertou parcial confissão (pág.09): “efetivamente trazia consigo a mochila contendo drogas, mas esclarece que as drogas não eram suas; tanto o entorpecente como o dinheiro que tinha consigo foram deixados com ele por um indivíduo chamado BRUNO, que havia acabado de sair para comprar bebidas alcoólicas em um bar, para consumirem. Salienta que ofereceu, sim, dinheiro aos policiais militares para que não o conduzissem até o Distrito Policial, porque não queria passar vergonha. Por fim, esclarece que, de fato, se agachou no mato, mas não sabe explicar porque procedeu dessa forma”.

Em Juízo, manteve a versão:

Dirigiu-se à trilha existente no local do fato para comprar droga. Tinha R\$80,00 em seu bolso, oriundo de seu trabalho na feira. Comprou uma porção de cocaína por R\$10,00. O traficante retirou a droga do bolso das vestimentas deles. Disse-lhe, então, que precisava comprar cigarro e bebida, pedindo que segurasse por breve tempo a sua mochila. Em seguida, foi abordado pelos policiais militares. Não tentou fugir. Não sabia que dentro da mochila havia substância entorpecente.

Quando soube que seria preso, perguntou aos policiais se haveria 'acerto'. Buscaria dinheiro com seu 'patrão', na feira, mas eles não aceitaram a oferta.

A negativa de dolo em relação ao crime de tráfico de droga ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares Alan dos Santos Canario e Victor Pimenta Mariano, em relato coeso e harmônico com o anterior, relataram os passos da diligência encetada na data dos fatos e espcaram qualquer dúvida quanto à autoria:

Realizavam patrulhamento nas imediações do local do fato quando moradores apontaram que na trilha existente na confluência da Estrada Alice Pereira de Souza com a Rua Iara de Pereira, ocorria tal mercancia ilícita.

Dirigiram-se ao local e ali avistaram o réu com uma mochila vermelha nas costas, sozinho e parado. Ao notar a presença policial, JOSÉ CÍCERO fugiu correndo, ingressando em um matagal. Perseguido sem que o perdessem de vista, localizaram o acusado ali agachado, tentando se esconder.

Detido, em vistoria na mochila que o acusado portava encontraram porções individuais de crack e de cocaína em pó, além de dinheiro trocado.

Inquirido, o agente confessou a prática do crime, afirmando que trabalhava na feira e exercia havia pouco tempo o tráfico de droga. Informou que o dinheiro era oriundo do tráfico de droga.

Detido, ao ser informado de que seria conduzido à Delegacia de Polícia, JOSÉ CÍCERO lhes ofereceu dinheiro, tentando convencê-los a não efetuar a prisão.

Primeiramente, disse “será que não dá pra fazer um acordo?”. Indagado sobre o que aquela frase queria dizer, confirmou que pretendia entregar dinheiro para ser liberado.

O acusado não estava sob efeito de droga e raciocinava normalmente.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p.

39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Neste sentido:

"Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes." (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.^a T., DJe 26/10/2018) Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16.^a Câ. Crim., julgado em 27/01/2015).

Quanto à ausência de qualificação de testemunhas civis, cumpre anotar o horário da abordagem do réu – madrugada. A par de reduzida circulação de pessoas em razão do horário, fato é que os policiais militares não realizaram campana no local, deparando-se com o réu assim que ingressaram na trilha onde moradores apontavam a prática da mercancia ilícita. E, em relação aos moradores, cabe destacar a conhecida 'lei do silêncio' que impera nas Comunidades da Comarca.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a quantidade e a espécie da substância entorpecente apreendida (28 invólucros plásticos de cocaína e 31 invólucros plásticos contendo crack), a forma como acondicionada (individualmente), o local da prisão (conhecido ponto da mercancia ilícita), a apreensão de dinheiro trocado (R\$81,00) e as circunstâncias da prisão (fuga do agente) tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, conforme preconiza o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, cumpre anotar, outrossim, que a circunstância do réu não ter sido preso no momento em que efetuava a venda da droga a usuário, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia.

Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consoma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na

denúncia, não sendo exigível, necessariamente, a prática de atos onerosos, pois suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não se olvida que JOSÉ CICERO se declarou usuário de droga e afirmou que, na data do fato, havia consumido substância entorpecente.

Ainda que fosse adotada como verdadeira, a premissa não teria o condão de afastar a culpabilidade do réu.

Em Juízo, o acusado não apresentou indicativo apto a revelar comprometimento de sua capacidade cognitiva em razão do uso de substância entorpecente. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura.

Fato é que, preso desde janeiro de 2022, não foi relatada nos autos alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química. O acusado não se declarou dependente químico, não há pedido defensivo para instauração do incidente de dependência químico-toxicológica e o Juízo não vislumbrou elementos para a sua determinação de ofício.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Os policiais militares, ademais, informaram que o acusado não aparentava estar sob efeito de droga e apresentava raciocínio regular e coerente.

Ainda nessa quadra, saliente-se que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante. É sabido que, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

"A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Também não merece guarida a tese do estado de necessidade.

A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

Inexiste nos autos prova de que o agente agiu para se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal e do qual não se desincumbiu a contento.

Eventual dificuldade financeira não autoriza, por si só, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de

drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade.

(...)

Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

O delito de corrupção ativa praticado pelo acusado também está cabalmente demonstrado.

Como ficou acima demonstrado, JOSÉ CÍCERO ofereceu aos policiais militares vantagem econômica indevida para evitar a sua prisão.

O próprio acusado admitiu em Juízo ter perguntando aos condutores de sua prisão se haveria 'acerto', visando entregar quantia em dinheiro para não ser preso. Os policiais confirmaram a oferta, acrescentando que, inquirido se buscava corrompe-los, o agente confirmou que sim, que conseguiria dinheiro para determiná-los a omitir ato de ofício e legal.

Configurada, portanto, a conduta prevista no artigo 333, caput, do Código Penal. A alegação de que o acusado não possuía quantia razoável quantia em dinheiro não afasta, por si só, a prática do crime.

É comum que o dinheiro oferecido seja levado ao ponto de droga por terceiro contatado pelo traficante.

Embora a oferta não tenha sido aceita na hipótese vertente, realizando-se a prisão do agente, o crime consumou-se porque é formal. Eventual recebimento da vantagem constituiria exaurimento e causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Portanto, o acusado realizou condutas típicas - artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 333, caput, do Código Penal - antijurídicas e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e as penas, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente desfavoráveis ao acusado, primário e sem antecedentes criminais.

A quantidade de droga não configura conduta que se diferencia dos demais casos similares. Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (tráfico) e 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (corrupção ativa).

Não há agravantes a considerar. Embora presente a confissão espontânea (CP, art.65, I e III, "d"), deixo de reduzir a reprimenda porque as atenuantes não permitem a fixação abaixo do mínimo legal previsto em lei para o crime (Súmula 231 do STJ).

Não há causas de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O réu preenche todos os predicados legalmente previstos. É primário, não ostenta antecedentes criminais e não há prova de que se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa.

Não há óbice à aplicação do índice redutor máximo, considerando-se a quantidade de droga apreendida em poder do réu.

Assim, pelas razões alhures, reduzo a pena em 2/3, o que perfaz 01 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. O índice é proporcional à conduta perpetrada pelo acusado.

Somadas as penas dos dois delitos, em razão do concurso material, consolida-se o montante de 03 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 176 dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a aparente situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento da pena fixada para cada crime, é o aberto. Não se desconhece que boa parte da jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena não altera a tipificação contida no caput do referido preceito legal (ou seja, em que pese a possibilidade de se aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas, ainda hediondo).

Esse entendimento chegou a ser reforçado pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.” (Súmula 512, Terceira Seção, julgado em 11/06/2014).

Ocorre que, no julgamento do HC nº 118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado.

Para o Supremo Tribunal Federal, havia evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos (Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo apresentam contornos menos gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência.

Essa decisão foi acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.

Ainda assim, tais decisões encontravam-se desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam adstritos ao entendimento ali professado.

Ante a inexistência de resolução do Senado acerca do assunto em debate, tampouco edição de Súmula Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram seu posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a crimes de natureza hedionda.

Esse foi no entendimento perfilhado por este Juízo por anos, mantendo-se a natureza de crime hediondo mesmo ao agente que recebia os beneplácitos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Ocorre que a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”) trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006” (grifo nosso).

A despeito de o legislador não ter escrito expressamente que o tráfico de drogas previsto no §4º (“tráfico privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o “tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de que tais delitos “apresentam contornos menos

gravosos e levam em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência”.

Adotar uma premissa válida para a Lei de Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois pesos e duas medidas”.

A persecução penal, fundamentalmente, está separada em três fases bem distintas, a saber:

A investigação, o processo judicial de conhecimento e a derradeira, sua fase de execução. Ora, como é possível o legislador não considerar o tráfico privilegiado perante o Juízo de Execução como crime hediondo, dizendo com todas as letras tratar-se de crime comum, e, ao revés, continuar sendo crime hediondo perante o juiz do processo de conhecimento. O direito é único.

No entanto, o direito, como ciência que é, está sujeito a alterações de acordo com a realidade e a acomodação social, possibilitando, sempre, sua interpretação e modificação de entendimento, no todo, ou em parte.

Por tais razões, este Juízo alterou, nessa parte, posicionamento anterior, depois de muita reflexão e ponderação, para pensar de maneira diferente o assunto relacionado ao denominado “tráfico privilegiado”, conferindo benefícios ao agente, quer no que respeita ao montante da reprimenda, quer em relação ao regime inicial para expiação da pena corporal.

Diante das alterações legislativas recentes, deve ser realizada interpretação sistemática, passando-se a adotar o tráfico privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o aberto.

Fundamenta-se o regime na exegese do artigo 59, caput, e seu inciso III, do Código Penal, a qual faculta ao magistrado, dentre todas as peculiaridades do processo, suas consequências, e atendendo aos outros predicados do citado artigo, estabelecer a pena concreta dentre aquelas cominadas, bem como o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pena base foi fixada no mínimo legal. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedica à atividades criminosas. Sendo assim, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo regime inicial aberto para o cumprimento das reprimendas.

Cumpre-se, outrossim, a recente decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.

De outra parte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do “sursis”, não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A concessão de tais benesses descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Na espécie, o réu portava quantidade razoável de droga. Embora seja possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito não constitui medida recomendável pois não teria o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

A quantidade de droga apreendida em poder do réu, de natureza diversa (crack e cocaína) torna a conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social, mormente em relação à cocaína. O crime é de perigo abstrato.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado JOSÉ CÍCERO DA SILVA, qualificado nos autos às págs.24/27 e 35, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 333, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto,

e ao pagamento de 176 dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme retro detalhado.

O réu respondeu ao processo preso, convertida sua prisão em flagrante em preventiva às págs. 52/55. Diante da pena e regime aplicados, o réu poderá recorrer em liberdade, não mais presentes os requisitos da prisão preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Decreto o perdimento do dinheiro, oriundo do tráfico de droga, e da mochila usada para a guarda e transporte da droga.

De imediato, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição da substância entorpecente apreendida nos autos.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados e tornem os autos conclusos para designação de audiência admonitória;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

d) Efetue-se a transferência do dinheiro apreendido nos termos das NSCGJSP, efetuando-se as comunicações necessárias.

e) Oficie-se à Autoridade Policial para destruição da mochila apreendida, usada para a guarda e transporte das drogas.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA